

予備独自問題R 4-16

(配点：2)

月 日

月 日

体液等の採取に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 強制採尿のための搜索差押許可状には、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件を記載することが望ましいが、かかる記載は不可欠ではない。

イ. 身体を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿のための搜索差押許可状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができる。

ウ. 尿を任意に提出しない被疑者の体内からカテーテルを用いて強制的に尿を採取することは、被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、捜査上真にやむを得ないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経て行うことが許される。

エ. 警察官が強盗殺人事件の捜査において、搜索差押許可状の発付を受けることなく、被疑者が不要物として公道上のゴミ集積所に排出したゴミ袋を領置することは、違法ではない。

オ. 被疑者の唾液を採取する場合は、被疑者がこれを任意に提出することを承諾したとしても、唾液に含まれる口腔内細胞は遺伝情報を含むから、身体検査令状の発付を受けることなく、これを採取することはできない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No99	体液等の採取	正答率
予備R4-16	正 解	94%
	2	

ア 誤っている

本記述は、強制採尿のための搜索差押許可状に、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載は不可欠ではないとしている点で、誤っている。

最決昭 55.10.23 (百選 28 事件)。判例は、捜査機関が強制採尿を実施するには「搜索差押令状を必要とする」と解すべきである」とした上で、ただし、「身体検査令状に関する刑法 218 条 5 項〔注：現 6 項〕が右搜索差押令状に準用されるべきであつて、令状の記載要件として強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠であると解さなければならない」としている。捜査機関が強制採尿を実施するのに搜索差押令状が必要であることの理由として、判例は、「体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は搜索・差押の性質を有するものとみるべきである」ということを挙げている。また、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が必要不可欠であることの理由として、判例は、「右行為は人権の侵害にわたるおそれがある点では、一般の搜索・差押と異なり、検証の方法としての身体検査と共通の性質を有している」ということを挙げている。したがって、強制採尿のための搜索差押許可状に、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載は不可欠である。

イ 正しい

最決平 6.9.16 (百選 29 事件) により、本記述は正しい。

判例は、「身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができるものと解するのが相当である」としている。その理由として、判例は、「そのように解しないと、強制採尿令状の目的を達することができないだけでなく、このような場合に右令状を発付する裁判官は、連行の当否を含めて審査し、右令状を発付したものとみられるからである」ということを挙げている。

ウ 正しい

最決昭 55.10.23 (百選 28 事件) により、本記述は正しい。

判例は、捜査機関による強制採尿の実施が許されるかについて、「被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、犯罪の捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経てこれを行うことも許されてしかるべきであり、ただ、その実施にあたっては、被疑者の身体の安全とその人格の保護のため十分な配慮が施されるべきものと解するのが相当である」としている。その理由として、判例は、「右採尿につき通常用いられるカテーテルを尿道に挿入して尿を採取する方法は、被採取者に対しある程度の肉体的不快感ないし抵抗感を与えるとはいへ、医師等これに習熟した技能者によつて適切に行われる限り、身体上ないし健康上格別の障害をもたらし危険性は比較的乏しく、仮に障害を起こすことがあつても軽微なものにすぎないと考えられる」とことや、「右強制採尿が被疑者に与える屈辱感等の精神的打撃は、検証の方法としての身体検査においても同程度の場合がありうるのである」ということを挙げている。

エ 正しい

221 条、最決平 20.4.15 により、本記述は正しい。

判例は、警察官が、被告人の動静を観察する中で、被告人及びその妻が自宅付近の公道上にあるごみ集積所に出したごみを回収し、その中身を警察署内において確認し、現金自動預払機の防犯ビデオに写っていた人物が着用していたものと類似するダウンベスト、腕時計等を発見し、これを領置したという事案において、「被告人及びその妻は、これらを入れたごみ袋を不要物として公道上のごみ集積所に排出し、その占有を放棄していたものであって、排出されたごみについては、通常、そのまま収集されて他人にその内容が見られることはないという期待があるとしても、捜査の必要がある場合には、刑訴法 221 条により、これを遺留物として領置することができるというべきである。また、市区町村がその処理のためにこれを収集することが予定されているからといっても、それは廃棄物の適正な処理のためのものであるから、これを遺留物として領置することが妨げられるものではない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、「遺留した物」(221 条)には占有者の意思に基づかないでその所持を離れた物だけでなく、占有者が自己の意思によって占有を離脱させた物も含まれると解されており、ゴミ袋は微弱ながら権利性を考えることができるとしても、捜査の必要がある場合には違法とならない場合があるということを挙げている。したがって、警察官が強盗殺人事件の捜査において、搜索差押許可状の発付を受けることなく、被疑者が不要物として公道上のごみ集積所に排出したゴミ袋を領置しても、違法ではない。

オ 誤っている

本記述は、被疑者が唾液を任意に提出することを承諾したとしても、身体検査令状の発付を受けることなく、唾液を採取することはできないとしている点で、誤っている。

被疑者が唾液を任意に提出することに承諾した場合、その唾液を採取する行為は、任意処分であるので、令状の発付を受ける必要はない。なお、本記述と異なり、被疑者が唾液を任意に提出することを承諾していない場合について、警察官であることを秘して、DNA型検査の資料を得るために、唾液の付いた紙コップを回収する行為は、個人識別情報であるDNA型をむやみに捜査機関によって認識されない利益という重要な権利利益を侵害しており、強制処分に該当すると判断した裁判例(東京高判平 28.8.23)がある。

以上により、誤っている記述はアとオであり、したがって、正解は肢 2 となる。

